

1500409-49.2021.8.26.0394

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... em nossos Tribunais:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

2ª Vara Judicial

Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa - SP - cep 13380-094

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500409-49.2021.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500409-49.2021.8.26.0394

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DONDERE BRAGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs ação penal em face de EDUARDO DONDERE BRAGA pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/2006 porque, em tese, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 20:30h, na Avenida Carlos Botelho, nº 1333, Centro, na Comarca de Nova Odessa, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 09 invólucros plásticos e 01 bloco em forma de tijolo, com peso total de 421,4g de substância contendo TetraHidrocarnabiol (THC) e 3 invólucros plásticos com 5,8 gramas, contendo a substância cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2022. O réu foi notificado a apresentar defesa prévia (fls. 124). Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Ao final, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia com a condenação do réu sem a incidência da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 1343/2006.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, bem como requereu adequação do regime de cumprimento de pena uma vez que o réu encontra-se preso desde 17 de julho de 2019, em regime fechado e que, na hipótese de condenação,

teria o direito do benefício da progressão de regime prisional. Postulou também pela conversão da pena privativa em restritivas de direito.

Folha de antecedentes juntadas a fls. 204/206 dos autos. Certidão juntada a folhas 212/213, onde consta uma condenação sem trânsito em julgado com relação a fatos anteriores aos fatos apurados nestes autos.

Relatados, DECIDO.

Preliminarmente, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito especial previsto na Lei de Tóxicos, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em favor do réu.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 46, termos de depoimento de fls. 7/12 e pelo auto de exibição e apreensão de folhas 8/9.

A autoria é certa.

Em seu interrogatório, em solo policial, o réu fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado. Em juízo, disse que já foi processado anteriormente por tráfico de drogas. Tem 24 anos. Mora com os pais e com o irmão. Tem uma filha de 04 anos que reside com a genitora. Disse que trabalha como monitor escolar e que é autônomo e registrado em empresa de van escolar. Confirma que foi abordado durante a diligência e que estava sozinho. Desconhece a acusação. Entende que os indivíduos referidos pelos policiais e a droga não existem e que o local não é ponto de tráfico. Nega uso de drogas ou outra substância.

Contudo, a versão apresentada pelo réu restou isolada no contexto probatório posto que os agentes policiais foram contundentes ao narrar como se deu a sua prisão. A testemunha policial Eduardo disse que estavam em patrulhamento e ao entrar na avenida, logo avistaram uma viela onde estava o réu e mais duas pessoas. Ao perceberem a presença da viatura, desceram a viela e, diante da atitude suspeita, começou a perseguição. Perceberam que o réu enquanto corria, jogou ao solo um saco plástico preto. Na abordagem, dentro da blusa do acusado havia algumas porções de drogas e, após, durante as buscas na viela, foi encontrado o saco plástico com mais meio tijolo de maconha. Ele negou que estivesse vendendo drogas no local. O depoente confirmou ainda que, próximo ao réu, havia uma bicicleta, e que ele cooperou com a atuação policial. Não soube dizer se havia imóvel com acesso à viela. Não se lembrou da iluminação mas disse que no dia estava bem escuro. O testemunha policial Vítor confirmou a narrativa do seu colega de farda. Contou que viram três indivíduos na entrada de uma viela efetuando a entrega de algo a outra pessoa que estava na viela. Confirmou a apreensão da droga na posse do acusado, além de R\$ 80,00 em dinheiro trocado e um celular. Disse que lembra de o réu estar com uma bicicleta próxima. Quando viu que seria preso, começou a reclamar um pouco. A viela estava escura. Afirmou que o saco plástico estava jogado na viela com drogas e como o réu estava com as drogas, concluiu-se que o saco lhe pertencia, já que ele dispensara um saco plástico quando da aproximação da viatura.

De resto, nenhuma testemunha de defesa foi arrolada com o fim de provar a versão apresentada pelo acusado.

Ressalto que o depoimento de agentes policiais é perfeitamente válido, pois não restou comprovada nenhuma agressão, ameaça ou perseguição que pudesse ensejar suspeita de acusação injusta ou forjada contra o réu. São os milicianos recrutados mediante concurso público para prevenir e reprimir o crime. São compromissados como qualquer outra testemunha, cabendo o ônus da prova da parcialidade dos depoimentos prestados à Defesa. Ainda, as hipóteses de suspeição e impedimento têm previsão legal exaustiva. Portanto, sem razão de ser a alegação que busque macular de vício os testemunhos harmônicos prestados pelos policiais militares.

Ainda sobre a admissibilidade de testemunhos de policiais, cita-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha a fim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas,

porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório. (TJSP - Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: o ilustre Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U. - g. n. ).

TJSP-080877 NENHUM HOMEM INOCENTE, PODENDO FALAR, PREFERE O SILÊNCIO PARA DEFENDER-SE DE INJUSTA ACUSAÇÃO. SE PERMANECEU CALADO, AINDA QUE DIREITO SEU GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART 5º, LXIII) DIFICILMENTE SE EXIMIRÁ DE JUÍZO ADVERSO. - A apreensão de grande quantidade de tóxico em poder do acusado argui para logo idéia de tráfico (art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, Lei de Drogas). - A inidoneidade das testemunhas não se presume; ao argüente impõe-se demonstrar, além de toda a controvérsia, que faltaram à verdade ou caíram em erro de informação. É que, na busca da verdade real - alma e escopo do processo-, "toda pessoa poderá ser testemunha" (art. 202 do Código de Processo Penal).- Vale o depoimento pelo grau de veracidade que encerra. Com respeito aos policiais, há decisão histórica do pretório excelso: "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (HC nº 51.577; 07.12.73, p. 9.372; apud Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, 22ª Ed., p. 187). - O justificado rigor, com que a Lei nº 8072/90 tratava os crimes denominados hediondos, foi atenuado pela Lei nº 11.464/2007, que lhe introduziu modificação no art. 2º, §1º, para permitir a seus autores progressão no regime prisional após o cumprimento, sob o regime fechado, de 2/5 da pena se primário, ou 3/5, se reincidente. (Apelação Criminal nº 993080127166, 5ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Carlos Biasotti. J. 29/05/2008).

Assim, não se demonstrando que os agentes de segurança (policiais ou guardas municipais) tenham mentido ou que existam fundados motivos para tanto, não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. Desse modo, observo que tais depoimentos, colacionados nos autos, estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente, quanto ao fato de o réu possuir a droga para fins de mercancia, revestidos, assim, de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Ademais, o elenco probatório não se resume apenas aos depoimentos dos agentes policiais; contém provas materiais (apreensão da substância tóxica, constatação e pesquisa em material estupefaciente) que configuram a tipicidade e que compõe um juízo de convicção seguro da materialidade do delito, assim como de sua autoria, mormente diante da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do delito. Essa é a posição consagrada em nossos Tribunais:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP - AC 20.239 - Rel. Geraldo Gomes-RT 584/347).

E para a configuração do delito de tráfico, é preciso cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei 11.343/06, quais sejam: a) a natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e d) conduta e antecedentes do agente, não se exigindo prova direta, especialmente com testemunho presencial de mercancia, porquanto uma das características de tal delinquência perversa é a clandestinidade, embora notoriamente difundida.

Demais disso, ainda que a prova dos autos não fosse conclusiva quanto à demonstração da autoria e materialidade do fato, é certo que prevalece no direito moderno o princípio da persuasão racional, fruto da moderna compreensão da atividade jurisdicional, de sorte que absolver o réu sempre que as provas se revelem indiciárias implica o estabelecimento de apriorismos indesejáveis, de modo

a inflexibilizar as decisões nos casos em que a própria causa se declare com essa feição circunstancial.

Sendo assim, considera-se suficiente para a condenação a constatação de indícios e circunstâncias que autorizem, indubitavelmente, a conclusão da prática de uma das condutas típicas previstas na lei especial. Isso porque, certamente, não seria possível demonstrar a negociata entabulada entre o acusado – traficante – e os demais usuários, uma vez que delitos nesta natureza são caracterizados pela clandestinidade, sob pena de se escancarar a impunidade.

“O comércio ilícito de drogas é comprovado pelas circunstâncias da prisão, a forma do material tóxico apreendido, a conduta do acusado e pelas informações das testemunhas da prisão. Tais indícios levam à conclusão inequívoca da mercancia, admitindo uma condenação, na ação penal” (Ap. crim. N. 32.516, de Curitiba, Rel. Dês. Sólon d’Eça Neves, j. em 28/3/95).

E as circunstâncias da apreensão confirmam que o destino do entorpecente era o tráfico ilícito. Isso ficou claro, diante do acondicionamento da droga apreendida aliado à atitude suspeita do réu, que atirou uma sacola plástica contendo drogas ao solo ao ver a aproximação da viatura; assim também, pelo fato de estar ocioso em local conhecido como ponto de tráfico, acompanhado de mais dois indivíduos numa viela entregando algo para outras pessoas, além de não ter justificado de maneira convincente a sua presença ali, que não fosse visando à prática de ilícito penal. Ressalte-se que dessa prática de tráfico resulta o dano causado pelo réu ao bem jurídico tutelado – saúde pública – fomentando a intensa criminalidade local para a busca de entorpecentes pelos viciados em tóxicos.

Todas essas circunstâncias, somadas às demais provas relacionadas à autoria delitiva, levam à certeza de que o entorpecente apreendido era destinado à comercialização.

O acervo probatório, assim, demonstra a culpabilidade do acusado, afastando a pretensão da Defesa pela desclassificação do delito até porque o réu negou o uso de drogas ou dependência química, o que leva a crer que o objetivo era unicamente a venda do entorpecente a terceiros. Ademais, se o uso de drogas fosse verdade, poderia ter demonstrado tal dependência através do incidente de dependência toxicológica ou teria tecido considerações sobre as dificuldades por que passa um drogadito, no seu contexto familiar e social, ou, até mesmo, sobre as suas tentativas de se libertar do vício.

Em suma, não havendo indícios nos autos de que o réu seja viciado em tóxicos a retirar-lhe o discernimento para o caráter ilícito do fato, fica afastada a possibilidade de desclassificação para a figura típica do art. 28, caput, da Lei 11343/2006.

Ademais, a Defesa não fez qualquer outra contra-prova capaz de desbancar o laudo toxicológico juntado aos autos e os depoimentos prestados em juízo.

Portanto, considerando essas razões e havendo prova incontestada da autoria e da materialidade do delito, bem assim ausente qualquer causa que afaste a tipicidade, antijuridicidade da conduta e a culpabilidade, vislumbro que o réu efetivamente incorreu na prática do crime de tráfico tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11343/2006, sendo imperiosa sua condenação.

Analisando as diretrizes traçadas pelos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, de relevante apenas observo que há uma condenação sem trânsito em julgado, mas que não justifica a aplicação da pena acima do mínimo legal.

Por ser primário e atender aos demais requisitos legais, possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar de 1/2, eis que o réu não apenas guardava a droga mas estava em local propício para o comércio, tudo a indicar que já o estivesse realizando.

Fixo a pena definitiva do réu então em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por disposição expressa de lei (art. 2º da Lei 8072/90), bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso.

Possível a aplicação do artigo 44 do Código Penal, por preencher o réu todos os requisitos necessários para tanto, fazendo jus o réu, desta forma, à substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de

direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestações de serviços à comunidade em local a ser definido pelo Juízo da Execução, e de prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários-mínimos vigentes à época do fato, por se revelarem as mais adequadas ao caso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu EDUARDO DONDERE BRAGA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei

11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por disposição expressa de lei (art. 2º da Lei 8072/90), bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso. Fica desde já autorizado o cálculo de pena considerada a detração, com relação ao tempo de custódia cautelar, a ser calculada pelo Juízo da Execução.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestações de serviços à comunidade em local a ser definido pelo Juízo da Execução, e de prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários-mínimos vigentes à época do fato, por se revelarem as mais adequadas ao caso.

Diante da aplicação da pena restritiva de direitos e, sobretudo com o possível resultado da detração, defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Custas na forma da lei, expedindo-se certidão se necessário.

Oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se.

Nova Odessa, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA